

1500186-48.2020.8.26.0486

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Quatá

Foro: Foro de Quatá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... o usuário, como destinatário final do tráfico, fomenta, por consequência, atividade criminosa. A pena de advertência, por exemplo, tem por objetivo o desestímulo ao consumo de drogas, que sabidamente é fonte de inúmeros outros problemas sociais, criminais, de saúde, etc.

E daí emerge o interesse em sua repressão, para muito além da só opção pessoal de cada indivíduo.

Ademais, o E. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Quatá

Foro de Quatá

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Rui Barbosa, 844, Quatá - SP - cep 19780-000

1500186-48.2020.8.26.0486 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500186-48.2020.8.26.0486

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DOS SANTOS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

De pronto, sustenta a Defesa a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, que protege a inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

Pois bem.

São núcleos do art. 28 da Lei n. 11.343/06: “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para uso pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

Trata-se de norma de interesse social, que objetiva a tutela da saúde pública, bem jurídico constitucionalmente tutelado, diante dos efeitos nocivos do uso de drogas. A conduta típica não é o consumo de entorpecentes, de forma que não está sendo punido o agente por suas escolhas pessoais – são penalizados os comportamentos que giram em torno e mesmo em função delas.

A tipificação da conduta não configura intervenção estatal indevida a ponto de interferir na intimidade e na vida privada uma vez que o comportamento excede a

esfera individual pois o usuário, como destinatário final do tráfico, fomenta, por consequência, atividade criminosa. A pena de advertência, por exemplo, tem por objetivo o desestímulo ao consumo de drogas, que sabidamente é fonte de inúmeros outros problemas sociais, criminais, de saúde, etc. E daí emerge o interesse em sua repressão, para muito além da só opção pessoal de cada indivíduo.

Ademais, o E. Tribunal de Justiça deste Estado bem reconhecendo a tipicidade da conduta:

Apelação Criminal - Posse de entorpecentes para uso pessoal - absolvição por atipicidade de conduta fundada na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 - Crime de perigo abstrato - Bem jurídico tutelado é a saúde pública - fomento ao tráfico de entorpecentes - Inconstitucionalidade - não ocorrência - Matéria de repercussão geral - Reserva de plenário nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 10 - Julgamento pelo STF suspenso -- Pena de advertência - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1505481-29.2021.8.26.0196, Relator: Rodrigo Miguel Ferrari, Data de Julgamento: 28/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022).

PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade. Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento. (TJSP Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608, Relator Alcides Malossi Júnior j. 23/06/2020)

Considerando que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e o julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506/STF) permanece suspenso, não se revela possível a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, como pretendido pela Defesa, sobretudo diante da reserva de plenário, prevista pelo art. 97 da CF: "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público".

Sendo assim enquanto não concluído o julgamento e não declarada a inconstitucionalidade pelo STF, considera-se norma vigente e presumida a constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pela Defesa.

Feita tal consideração, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público deste Estado imputa ao acusado a prática do crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/09.

Segundo consta da denúncia, o denunciado Fábio dos Santos Ferreira, guardava, portava e trazia consigo para consumo pessoal 01 porção de droga popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, fora encontrada planta, consistente na mesma substância, plantada em uma caneca, também para consumo próprio e destinado a preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Segundo narrou a denúncia, na data dos fatos (06/08/2020), a Polícia Militar foi acionada para averiguar a prática de violência doméstica do acusado contra sua esposa. Ao chegarem no local, adentraram ao imóvel com autorização do proprietário, e apreenderam no quarto do denunciado as porções de drogas acima mencionadas, destinadas ao consumo pessoal do denunciado.

Não obstante os argumentos trazidos pela nobre Defesa, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pela requisição de IC (fls. 19), pelos laudos periciais (fls. 20/31) e pelos depoimentos prestados na delegacia de polícia (fls. 12/15) e na prova oral colhida em audiência.

A autoria é certa e recai sobre o denunciado, diante da prova oral produzida em juízo.

Em juízo, a testemunha Ezequiel do Nascimento, policial militar, afirmou que “os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e quando chegaram ao local, o réu estava no quintal e a esposa não mais estava lá, tendo então o depoente começado a conversar com o réu. Apontou que a esposa viu a polícia e compareceu ao local, pedindo para reingressar na residência para pegar as coisas. Apontou que, mesmo na frente da viatura, o réu passou a falar que iria matá-la, cortando o pescoço dela. Apontou que depois conversaram e a esposa autorizou a entrada da polícia, levando os policiais ao local onde havia um pedaço de pau com prego na ponta que ela relatou que ele usava para agredi-la, sendo que, na residência, avistaram ainda as drogas e a planta de maconha plantada. Apontou que, diante disso, apreenderam o bastão, a droga e a planta e conduziram ambos para a delegacia. Apontou que, enquanto a esposa pegava as coisas dela na casa, o réu estava bem agitado. Afirmou que foi a esposa Aline que indicou o local das drogas. Apontou que, salvo engano, tinha uma criança junto e, pelo que se recorda, a esposa Aline pegou roupas sua e também uma para a criança para sair. Apontou que, na época, ninguém mencionou que o réu e a esposa estavam separados, sendo que, pelos elementos, entendiam que os dois estavam juntos. Por fim, afirmou que pós localizarem as drogas, o réu afirmou que seria dele e que seria para uso”.

No mesmo sentido foi o que declarou a testemunha Lidio Navarro Garcia Neto, também policial militar, que em audiência afirmou “que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e quando chegaram ao local, o réu estava no quintal e a esposa não mais estaria lá. Apontou que o réu Fábio relatou que tiveram uma discussão porque a esposa teria tido uma recaída e ficado fora da casa para usar drogas. Apontou que a esposa Aline viu a viatura e voltou no local, e lá chegando falou que tinham drogas e um pedaço de pau que ele usava para agredi-la, e ambos autorizaram o ingresso na residência, local em que localizaram as drogas e o réu de pronto afirmou que eram dele. Apontou que, no atendimento, o réu chegou a ameaçar a esposa Aline falando que iria cortar o pescoço dela”.

Em que pese o declarado pela informante Aline Aparecida da Silva, esposa do réu, que afirmou em audiência “ter voltado a se relacionar com o denunciado e não se recordar dos fatos e nem de ter sido encontrado droga com o réu. Complementando que a residência era dele e que, quando a polícia entrou, não havia autorizado os policiais a entrarem e ao ser indagada sobre seu depoimento na polícia, afirmou que não se recorda de o ter prestado”, o próprio denunciado Fábio dos Santos Ferreira assumiu que a droga encontrada na residência era sua, assim como o imóvel e que não autorizou o ingresso dos policiais militares a casa na data dos fatos.

Pois bem.

Pela oitiva colhida em juízo, verifico que as declarações das testemunhas são harmônicas e coerentes entre si, além de trazerem as mesmas informações que já haviam sido relatadas perante a autoridade policial.

Nesse ponto, destaco que embora o denunciado tenha negado a alegação de que teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial e em juízo apontam em sentido contrário, em especial por ter a testemunha Ezequiel do Nascimento declarado que a entrada à casa deu-se por autorização da esposa do réu, Sra. Aline, presumindo-se sua qualidade de proprietária do imóvel.

Quanto ao crime propriamente dito, observa-se que o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 é de perigo e para sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevante a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto.

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Recurso de Apelação. Posse de entorpecentes para consumo pessoal. Recurso da defesa que pretende obter a absolvição do réu firme nos argumentos de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é inconstitucional ou que o fato é atípico por força do princípio da insignificância. Matéria ainda não decidida em caráter definitivo pelo STF. Vigência e constitucionalidade da norma criminalizadora que persistem. O tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é polêmico e ganhou significativa importância jurídica, mercê da deliberação do Excelso Pretório de lhe emprestar relevância geral (RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes), não tendo ocorrido ainda o seu julgamento definitivo. Na ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo guardião mor da Constituição, e tendo em conta que os Tribunais Superiores, ainda que sem ferir diretamente o tema, vêm aplicando e se referindo ao referido dispositivo legal sem proclamar a eiva à Carta Republicana (cf., por exemplo, STF, RE nº 430.105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, HC nº 350.317, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; HC nº 339.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 347.779, Rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 177.012, Rel. Min. Gilson Dipp), há que se prestigiar o princípio hermenêutico de que se presume constitucional um ato legislativo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. Entendimento vigente nos Tribunais Superiores de que não ocorreu a descriminalização, mas a despenalização. Crime de perigo abstrato que não comporta a aplicação do princípio da insignificância. Tratando-se de réu primário e de fato envolvendo pequena quantidade de maconha, é mais razoável fixar a pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Recurso da defesa parcialmente provido, apenas para fixar a pena de advertência. (TJ-SP – Apelação Criminal n. 1500054-05.2020.8.26.0352, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data de Publicação: 18/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 387.874/MS , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

Assim, não sendo caso de se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal ou da aplicação de princípio da insignificância e tampouco de se afastar a constitucionalidade da norma prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06, mas por outro lado, comprova a autoria e materialidade dos fatos, entendendo pela aplicação de advertência ao denunciado.

Quanto a dosimetria, trata-se de réu primário, que confessou a prática do delito, inserido em meio familiar conturbado, exercendo os cuidados e responsabilidade de seus dois enteados, a quem despense atenção e cuidados suficientes ao bom desenvolvimento dos menores, e provém o sustento familiar com seu trabalho como trabalhador rural, além de sua esposa ser usuária de substância conhecida como "crack", conforme declarado pela própria esposa perante autoridade pessoal. Ademais, a quantidade da droga apreendida é pequena, o que, corroborado com a primariedade do réu e o meio familiar em que se encontra inserido, permite a fixação da pena de advertência, a mais branda para esse tipo penal, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu Fábio dos Santos Ferreira, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de advertência.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Tendo em vista que o crime em tela não apresenta vítima determinada e diante da ausência de pedido, deixo de fixar valor mínimo da indenização.

Desde já, defiro ao requerido a justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente sentença, inclua-se o réu no rol dos culpados; oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se a respectiva guia de execução definitiva.

Arbitro honorários advocatícios em favor da Defensora do réu, no patamar máximo do convênio entre OAB/SP e DPE/SP. Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão de honorários.

P.R.I.

Quata, 27 de outubro de 2022.